

1506944-70.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO FONSECA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

MÁRCIO FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506944-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506944-70.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO FONSECA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

MÁRCIO FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de março de 2022, por volta de 01h55, na Travessa Itaipava, altura do nº 100, Brasilândia, nesta cidade e comarca da Capital/SP, agindo em concurso e com identidade de propósitos com 02 (dois) indivíduos não identificados, trazia consigo, para fins de traficância, 29 (vinte nove) porções de maconha e 162 (cento e sessenta e duas) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) em dinheiro (fls. 49/51).

Recebida a denúncia (fls. 61/62), o réu foi citado e notificado (fl. 94), apresentando resposta à acusação (fl. 97).

Mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e, ato contínuo, o réu foi interrogado (fl. 97).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu

nos exatos termos da denúncia (fls. 97/99).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu i) a fixação da pena-base no mínimo legal; ii) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal; iii) a fixação de regime prisional mais brando do que o fechado; iv) a detração penal; e vii) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 99/100). É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Termos de Depoimento (fls. 05 e 06), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), Laudo de Constatação (fls. 15/18 ou 74/77), Comprovante de Depósito do Dinheiro Apreendido (fls. 40/41), Relatório Final (fls. 42/43) e, sobretudo, pelo Laudo Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 78/80).

A autoria do crime ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Jéssica Aparecida Silva, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, em conhecido local de venda de drogas, seu companheiro de farda ingressou pela viela, pela parte de cima; dirigia a viatura no dia dos fatos e, a fim de fazer o "cerco", foi pelo lado oposto a ele. Ao desembarcar da viatura, viu MÁRCIO correndo, assustado, em sua direção; abordou-o e aguardou a vinda de seu parceiro policial, o qual "trazia consigo a sacola" - "tinham 03 (três) indivíduos, e o indivíduo dispensou a sacola no interior da viela, 02 (dois) correram, e o MÁRCIO veio na minha direção". Indagado, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Não viu quem dispensou a sacola ao solo; A sacola tinha - "cocaína, maconha, crack [...] tinha bastante coisa". O acusado não portava nada de ilícito. O réu não informou quem eram os outros indivíduos que conseguiram fugir do local. Não conhecia o acusado de abordagens anteriores. Repisou que "era uma sacola só"; "havia dinheiro" na sacola. Reafirmou que MÁRCIO confessou informalmente a traficância. Não trocou informações com seu companheiro de farda sobre quem teria dispensado a sacola com drogas na viela escura. Não presenciou atos de venda de drogas. Explicou que o local é conhecido ponto de traficância de entorpecentes, próximo a uma esquina onde há um "hortifrúti"; na esquina, vários usuários ficam parados consumindo drogas; o ponto de venda de entorpecentes é no fundo da viela, a qual é uma rua praticamente "sem saída"; as pessoas ingressam na viela e compram as drogas no fundo da rua e, posteriormente, voltam ao ponto da esquina para consumi-las; MÁRCIO, no dia da ocorrência, veio correndo em sua direção, enquanto as demais pessoas permaneciam tranquilas, sem dispersarem-se. Elucidou que Gabriel informou que os outros 02 (dois) indivíduos fugiram pela "rua de cima" - "sentido Joaquim Ferreira da Rocha".

Gabriel Ferreira de Oliveira, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Jéssica. Contou que o local da ocorrência é conhecido ponto de venda de drogas e diariamente são feitas incursões no local com o objetivo de coibir o comércio espúrio. No dia dos fatos, fizeram um cerco policial; ingressou na viela e viu 03 (três) indivíduos, os quais, ao avistarem-no, saíram correndo; 02 (dois) dos indivíduos correram para outra viela, enquanto o acusado tomou caminho para uma rua sem saída, onde estava sua companheira de farda, Jéssica, realizando o cerco. Um dos indivíduos dispensou a sacola ao solo; não conseguiu visualizar quem estava com a sacola nas mãos, ou se ela estava a tiracolo ou no chão - "a única coisa que eu conseguir ver foi a blusa que o MÁRCIO estava vestindo, que era uma blusa com três cores, uma jaqueta na verdade, e os outros dois com jaqueta escura, que aparentavam serem até menores de idade. Quando eles me viram, porque tava escuro né, eles correram, e a sacola ficou pelo local exatamente onde eles estavam, e o MÁRCIO foi em direção à Jéssica". Jéssica conseguiu deter o acusado. Narrou que, ao pegar a sacola, verificou que continha em seu interior substâncias aparentando serem drogas, além de dinheiro trocado em moedas. Repisou que os 03 (três) indivíduos estavam juntos, "exatamente no mesmo quadrado ali".

Indagado, MÁRCIO confessou que estava praticando a venda de drogas - "inclusive, ele mencionou detalhadamente pra nós os valores que cada droga era vendida, as porções maiores, as menores, sendo o valor de cinco reais as menores, as maiores, de dez reais, e que o ganho que ele obteria naquele dia seria o equivalente ao que fosse ganho naquele turno de serviço né. [...] Uma certa porcentagem [da venda]". Elucidou que MÁRCIO estava "somente" como "funcionário", vendendo drogas pertencentes, possivelmente, a outra pessoa. Não conhecia o acusado de abordagens anteriores. Alinhavou que o local, próximo a um hortifrúti, é um ponto de concentração de usuários de drogas, servindo, inclusive, de "termômetro" para identificação da traficância. Esclareceu que quando aglomeram muitas pessoas no hortifrúti - "aí nós temos certeza absoluta que tá sendo vendida a droga". O local é próximo a "uma escola, uma creche". Não teve acesso ao depoimento prestado pelo acusado perante a D. Autoridade Policial. Repisou que, dentre todas as pessoas presentes no local dos fatos, "somente os 03 (três)" correram ao virem a aproximação da diligência policial. No momento, foi fácil identificar MÁRCIO, mesmo na escuridão, pelas cores vibrantes de sua jaqueta. Assentou que o acusado estava com uma marmita na mão quando fugiu; durante a abordagem, viu que a mão do réu estava suja de comida - "pelo susto que ele tomou". Conseguiu visualizar o rosto e o semblante do acusado; não teve dúvidas que fora ele quem corra do ponto de tráfico. Reconheceu o acusado em juízo.

Em solo policial, o acusado negou a prática delitiva (fl. 07). Em juízo, MÁRCIO continuou negando os fatos. Disse que estava no local da ocorrência porque é morador. A droga encontrada na sacola não era sua. É usuário, não traficante. No dia dos acontecimentos, estava sozinho na viela.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

Por primeiro, a versão do acusado ficou isolada do conjunto probatório.

É dizer, a versão apresentada pelo réu não convence.

O policial Gabriel, a seu turno, foi preciso em narrar que viu MÁRCIO, juntamente de outros 02 (dois) indivíduos, exatamente no lugar onde a sacola contendo as drogas e dinheiro foi localizada, tendo todos fugido assim que visualizaram-no. Além de ter fugido ao avistar a polícia, os policiais foram uníssomos em asseverar que o acusado confessou a traficância, inclusive dando detalhes sobre a empreitada delitiva, com precificação dos entorpecentes e porcentagem de lucro a ser recebida pela venda.

Note-se também que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo foram no mesmo sentido de seus relatos em sede investigativa (fls. 05 e 06).

Aliado aos depoimentos dos policiais, a quantidade de drogas apreendidas, sua forma profissional de acondicionamento (fls. 78/80) e o local em que o réu estava são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando provada a origem espúria da quantia apreendida.

Importa ressaltar que é irrelevante para a configuração do delito de tráfico de drogas que o autor não tenha sido surpreendido vendendo os entorpecentes, haja vista que é suficiente o dolo específico de praticar qualquer das condutas previstas como ilícitas no artigo 33, caput, da Lei 11.373/06. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (REsp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais

nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que pequenas divergências em seus relatos, normais em virtude de participarem de várias diligências semelhantes, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Pontue-se, pois oportuno, que a condição de dependente químico, apesar de alegada pelo réu não foi comprovada e, de todo modo a alegação não tem o condão de excluir automaticamente o enquadramento típico do crime de tráfico de drogas, notadamente porque, em grande parte dos casos, os usuários de entorpecentes, infelizmente, praticam a mercancia ilícita para conseguirem sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou suficientemente atestado que as drogas encontradas dentro da sacola que estava junto ao acusado, realmente pertenciam a ele e aos seus comparsas, bem como teriam como destino o consumo de terceiros.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

O réu possui 45 (quarenta e cinco) anos, é solteiro e tem três filhos, com 25 (vinte cinco), 19 (dezenove) e 14 (quatorze) anos de idade, respectivamente.

Estudou até o primeiro grau completo. Trabalha com reciclagem; recebe por volta de R\$ 100,00 (cem reais) por dia trabalhado. Reside em casa própria. Foi processado por tráfico de drogas em outras 02 (duas) vezes; afirmou que foi absolvido.

Na primeira etapa, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, sobressai a reincidência específica de MÁRCIO (Processo nº 0082429-54.2012.8.26.0050; pena julgada extinta em 16/08/2019 - fls. 19/21) e, por conseguinte, elevo as sanções na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento do i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição. Anoto a inviabilidade de aplicar a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pois não há laudo específico que aponte a proximidade do local da traficância com a mencionada escola de educação infantil "E.E. INFANTIL VIVER E APREENDER" (fls. 05 e 06).

Assim, as penas resultam, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar MÁRCIO

FONSECA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; c.c. artigo 61, I, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face da reincidência específica de MÁRCIO.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Oficie-se.

Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União, conforme o artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA